EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – CFOAB, serviço público dotado de personalidade jurídica e regulamentado pela Lei nº 8.906/94, inscrito no CNPJ sob o nº 33.205.451/0001-14, por seu Presidente e advogados infra-assinados, com instrumento procuratório específico incluso, endereço para intimações na SAUS Qd. 05, Lote 01, Bloco M, Brasília-DF e endereço eletrônico pc@oab.org.br, com base nos arts. 102, inciso I, alínea "a"; 103, inciso VII, da Constituição Federal, bem como no art. 2º, inciso VII da Lei nº 9.868/99 propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

em face das locuções "*infração ético-disciplinar"* e *"ato ímprobo"* constantes da redação conferida pela lei nº 14.110, de 18 de dezembro de 2020, ao artigo 339 do Código Penal, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB– Brasília/DF CEP 70070-939
Tel: 61 2193-9818 / 2193-9819 Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

I. DO ATO NORMATIVO E DO CONTEXTO FÁTICO:

Fruto do projeto de lei nº 2.810/2020, da Câmara dos Deputados, a Lei 14.110/2020 teve em seu nascedouro de proposição que se pretendia limitadora do alcance do tipo penal até então em vigor, já anteriormente reformado pela lei nº 10.028/00: "*dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente"*. Assim anotou a iniciativa parlamentar:

> *"Com efeito, as expressões '**investigação policial**' e '**instauração de investigação administrativa**' são muito amplas, genéricas e subjetivas, na medida em que um mero expediente como uma notícia de fato ou sindicância podem ser enquadrados como 'investigação', mesmo que não submetam o sujeito à condição de investigado e nem causem prejuízo à Administração.*
> *Por abranger um universo muito maior de condutas, a atual redação do art. 339 do Código Penal é fonte de injustiça e de inconstitucionalidade material, por contrariar princípios penais limitadores decorrentes da dignidade humana, havendo forçosamente que readequar o tipo penal à Constituição, substituindo-se a expressão '**investigação administrativa**' por '**processo administrativo disciplinar (PAD)**[1].*

A partir de tais premissas – cujos equívocos já serão observados – propunha-se a seguinte redação para o tipo legal: "*Art. 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, processo judicial, processo administrativo disciplinar, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente*".

Foi através de um substitutivo, proposto quando em discussão o projeto perante a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que o projeto teve a formatação que influenciaria decisivamente o texto final. Eis os fundamentos do substitutivo:

> "No tocante ao mérito, há de se reconhecer a pertinência e conveniência da matéria, tendo em vista que falta maior clareza e precisão à redação vigente do tipo penal inscrito no art. 339 do Código Penal. Entretanto, data venia ao texto sugerido pelo ilustre autor da proposta legislativa sub examine, entendo ser mais adequado ajustar o texto do tipo penal do crime de denunciação caluniosa à mens legis da Nova Lei de Abuso de Autoridade, Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019.
> Isto é, minha sugestão é de que a conduta típica do crime de denunciação caluniosa seja a de dar causa à instauração de inquérito policial, procedimento investigatório criminal, processo judicial, processo administrativo disciplinar,

[1] Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/144230> Acesso em 31 jul. 2025.

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB– Brasília/DF CEP 70070-939
Tel: 61 2193-9818 / 2193-9819 Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

> inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente".[2]

Pode ser esclarecedor o confronto entre o tipo legal da denunciação caluniosa (art. 339 CP), com a redação original de 1940 alterada pela lei nº 10.028, de 19.out.00, e o tipo legal resultante da lei cuja constitucionalidade ora é impugnada, a lei 14.110, de 18.dez.20:

Art. 339 CP, (redação original de 1940 alterada pela lei 10.028/00)	Art. 339 CP (redação estabelecida pela lei 14.110/20)
"*Art. 339. Dar causa à instauração de **investigação policial**, de **processo judicial**, instauração de **investigação administrativa**, **inquérito civil** ou **ação de improbidade administrativa** contra alguém, **imputando-lhe crime** de que o sabe inocente*".	"*Art. 339. Dar causa à instauração de **inquérito policial**, de **procedimento investigatório criminal**, de **processo judicial**, de **processo administrativo disciplinar**, de **inquérito civil** ou de **ação de improbidade administrativa** contra alguém, **imputando-lhe crime**, **infração ético-disciplinar** ou **ato ímprobo** de que o sabe inocente*".

A lei 14.110, de 18 de dezembro de 2020 não modulou a escala penal, isto é, seja no caso de imputação de um estupro (**crime**), seja a imputação de ter o advogado debatido em jornal causa sob o patrocínio de outro colega (**infração ético-disciplinar**[3]), seja a imputação de que o motorista do carro oficial levou a esposa do servidor público ao dentista (**ato ímprobo**[4]), a resposta penal do tipo previsto no art. 339 é a mesma: reclusão de dois a oito anos e multa. Como se vê, não há gradação nas penas aplicadas, em que pese a amplitude de condutas abarcadas pelo tipo penal.

O breve exame que se segue sobre as justificativas parlamentares deve principiar pela manifestação do maior respeito por sua legitimidade, provinda do voto popular. Se Madison certeiramente apregoava que "no governo republicano predomina necessariamente a autoridade legislativa", Hamilton vislumbrou na lei inconstitucional uma barreira a tal

[2] Disponível em:<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/144230>. Aliás, no Senado, a matéria não sofreu maiores alterações, conforme se vê do parecer do Relator do assunto naquela Casa.
[3] Prevista no artigo 42, inciso II do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.
[4] A conduta de "quem utilizar em (...) serviço particular veículos (...) ou trabalho de servidores públicos" é prevista como ato de improbidade administrativa (lei nº 8.429, de 2.jun.92, art. 9º, inc. IV).

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB– Brasília/DF CEP 70070-939
Tel: 61 2193-9818 / 2193-9819 Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

predomínio, ao argumento de que trai seu mandato o representante que legisla contra a Constituição; "consequentemente concluía ele – não será válido qualquer ato legislativo contrário à Constituição"[5].

Para substituir o elemento típico "**investigação policial**" por "**inquérito policial**", argumentou-se que a primeira seria muito "ampla, genérica e subjetiva", e que por si só tal procedimento não "submete o sujeito à condição de investigado e nem causa prejuízo à Administração". A investigação policial prévia ao inquérito, autorizada expressamente pelo artigo 5º, § 3º, do Código de Processo Penal, é realizada "pela autoridade policial a fim de verificar se instaura o inquérito policial"[6]. A notícia de crime chegada à Delegacia deve ser minimamente averiguada para evitar que uma pessoa viva figure como vítima de homicídio consumado no despacho que instaura o inquérito.

Regulamentada administrativamente pelos Estados da Federação e objeto especial de atenção dos Ministérios Públicos estaduais, a instauração formal da sindicância preliminar submete (sim) o sujeito à condição de investigado (se fosse em inquérito policial, tratar-se-ia de *indiciado*) e claramente causa prejuízo à Administração da Justiça e ao caluniado, titular dos bens jurídicos *honra* e *liberdade*, também afetados pelo crime de denunciação caluniosa. Apesar de todas as restrições à fundamentação, convém desde logo realçar que tal alteração não colide com a Constituição.

Quanto à substituição do elemento típico "**investigação administrativa**" por "**processo administrativo disciplinar**", seus abstratos fundamentos não escondem a catástrofe proposta. Como se sabe, a doutrina administrativista posterior à Constituição da República de 1988 divide os processos administrativos em três grandes classes: processos administrativos revisivos, processos administrativos sancionatórios e processos administrativos disciplinares[7]. A opção da lei ora impugnada tem o efeito absurdo de tornar atípica denunciação caluniosa que conduza à instauração de inquéritos administrativos sancionatórios, como alguns daqueles instaurados pelo Banco Central ou pela Comissão de Valores Mobiliários, por exemplo.

Os equívocos que fundamentaram o projeto legislativo e as inconveniências político-criminais que decorrem da nova lei teriam, contudo, que ser republicanamente

[5] Hamilton, Alexander - Madison, James - Jay, John, O Federalista, trad. H. A. Herrera, Brasília, 1984, ed. UnB, pp. 419 e 577.
[6] Batista Guimarães, Johnny Wilson, Imputação Criminal Preliminar e Indiciamento, B. Horizonte, 2017, ed. D'Plácido, p. 76. Sobre as decominadas VPI's – **V**erificação da **P**rocedência das **I**nformações (nome extraído do texto do CPP, art. 5º, § 3º) ou Verificação Preliminar ao Inquérito, Nicolitt, André, Manual de Processo Penal, B. Horizonte, 2018, ed. D'Plácido, pp. 221-222.
[7] Assim Valle Figueiredo, Lucia, Curso de Direito Administrativo, S. Paulo, 2000, ed. Malheiros, p. 406.

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB– Brasília/DF CEP 70070-939
Tel: 61 2193-9818 / 2193-9819 Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

digeridos por todos nós – esta é uma das bases do Estado de direito – caso algumas das opções do legislador não estivessem em aberto conflito com texto expresso e com princípios cristalinamente adotados por nossa Constituição. É o que se tentará demonstrar em seguida.

II. DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

A conscientemente falsa imputação de um ato de improbidade administrativa já era hipótese contemplada pela lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992:

> Art. 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade administrativa contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente.

A "novidade", portanto, já existia no direito brasileiro havia três décadas, e assim a emenda era completamente desnecessária. Antes da nova lei, era simples a equação: se o agente, através da imputação conscientemente falsa de um **crime**, logra a instauração de ação de improbidade administrativa, sua conduta seria apreciada segundo o artigo 339 CP; mas se o agente simplesmente formula a representação contendo **imputação conscientemente falsa de um ato de improbidade administrativa**, sua conduta seria apreciada segundo o artigo 19 da lei 8.429/92, cuja estrutura típica dispensa o resultado de *instauração de procedimento* que rege, enquanto seu momento consumativo, todas as modalidades da denunciação caluniosa codificada.

A alteração efetivada pela lei cuja inconstitucionalidade ora se sustenta substituiu o elemento típico "**ato de improbidade administrativa**" por "**ato ímprobo**" com grave lesão ao princípio da legalidade em sua função de taxatividade.

Ambas as expressões ("**ato de improbidade administrativa**" e "**ato ímprobo**") configuram *elementos normativos do tipo*. Tais elementos, ao contrário daqueles *descritivos*, implicam uma valoração que agregará sentido à conduta típica. Por isto mesmo seu descobridor, Max Ernst Mayer, os situava com uma perna na tipicidade (onde seriam quase "um corpo estranho") e outra na ilicitude[8]. Mas há entre ambos uma diferença relevantíssima.

Nos chamados *elementos normativos jurídicos*, a cuja classe pertence "**ato de improbidade administrativa**", a valoração complementar está previamente estabilizada pelo direito. Como ensinava o saudoso Luis Luisi, estamos aqui diante de "elementos do tipo já

[8] Mayer, Max Ernst, *Derecho Penal – P.G.*, trad. J. L. Guzmán Dalbora, Montevidéu, 2007, ed. B de f, p. 230.

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB– Brasília/DF CEP 70070-939
Tel: 61 2193-9818 / 2193-9819 Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

valorizados", de "valorações já realizadas pelo ordenamento jurídico", de "conceitos já expressos em normas jurídicas e com significações consagradas"[9]. Reproduzindo lição comum, Ruggiero distingue estes elementos "baseados em valorações expressas de direito positivo (*fondati su valutazioni espresse da altre sfere di diritto positivo*)" daqueles elementos normativos chamados "culturais", nos quais a valoração tem "caráter ético-social, econômico, de civismo (*civiltà*) etc"[10]. Quando o legislador emprega elementos normativos jurídicos, como por exemplo "duplicata" (art. 172 CP) ou "criança" (art. 135 CP), o direito cambiário ou o direito da infância e adolescência (art. 2º ECA) socorre o juiz, e a exigência de clareza e exatidão da lei penal está preservada.

Porém os elementos normativos culturais oferecem sempre aquele risco percebido por Asúa, de que o juiz "saia de sua tarefa própria (*salga de su genuíno menester*)"[11] e passe a legislar para o caso. A expressão "**ato ímprobo**", desgarrada de qualquer referência, abre as portas para a complementação valorativa do tipo por toda a sorte de preconceitos e de moralismo vulgar. A literatura penalística já advertira para tais riscos quanto ao "ato obsceno" (art. 233 CP)[12]; riscos mais presentes e mais graves no "**ato ímprobo**".

A violação do princípio da reserva legal, em sua função de taxatividade, por certos elementos normativos "flexíveis" ou "elásticos" é amplamente reconhecida pelos mais acurados estudos brasileiros. "Os elementos normativos do tipo objetivo implicam, por sua própria natureza, uma relação conflituosa com a legalidade", registra recente obra da catedrática da USP[13]. Para Santos Lopes.

> "É no plano da agressão à taxatividade que se insere a questão do uso de elementos normativos sem precisão semântica (...que) causam dificuldade interpretativa, agredindo a certeza jurídica e, por conseguinte, a própria legalidade"[14].

[9] O Tipo Penal, A Teoria Finalista e a Nova Legislação Penal, P. Alegre, 1987, ed. Fabris, p. 58.
[10] Ruggiero, Giuseppe, Gli Elementi Normativi della Fattispecie Penale, Nápoles, 1965, ed. Jovene, p. 99.
[11] Jiménez de Asúa, Luis, Tratado de Derecho Penal, B. Aires, 1965, ed. Losada, t. III, p. 905. Considerando um tipo legal hipotético grosseiramente inconstitucional ("quem violar o bem comum de forma inadmissível"), Roxin observa que a punibilidade neste caso não decorreria da previsão legal, "mas sim o juiz é que deveria estabelecer qual conduta afetou inadmissivelmente o bem comum (sondern erst der Richter müsste festlegen welches Verhalten in unerträglicher Weise gegen das allgemeine Wohl verstösst)" – Roxin, Claus, Strafrecht – A.T., Munique, 2006, ed. C.H.Beck, v. I, p. 142.
[12] "O juiz não pode, de forma alguma, realizar uma valoração jurídica puramente subjetiva, devendo ater-se a valores fixados, objetivos" – Fragoso, Heleno, Lições de Direito Penal, P.E., Rio, 1988, ed. Forense,v. II, p. 81.
[13] Liberatore Silva Bechara, Ana Elisa, Valor, Norma e Injusto Penal, B. Horizonte, 2018, ed. D'Plácido, p. 387.
[14] Santos Lopes, Luciano, Os Elementos Normativos do Tipo Penal e o Princípio Constitucional da Legalidade, P. Alegre, 2006, ed. Fabris, p. 152.

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB– Brasília/DF CEP 70070-939
Tel: 61 2193-9818 / 2193-9819 Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

Para Zaffaroni *et alii*, elementos "normativos extrajurídicos (ou culturais), e elementos vagos e indeterminados, totalmente normativos, fundados em pseudoconceitos de natureza emocional são inconstitucionais"[15].

Sem nenhum ganho político-criminal, a alteração legislativa sob exame afeta diretamente o princípio da reserva legal (art. 5º, inc. XXXIX, CF). A expressão abandonada, "**ato de improbidade administrativa**", é clara e unívoca: trata-se de um gênero de condutas cujas espécies estão previstas na lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, nos doze incisos do artigo 9º e nos quinze incisos do artigo 10. A complementação homóloga (a lei é aqui complementada por outra lei) sinaliza o caráter absoluto da reserva legal, e a tipologia da lei limita taxativamente o campo de pesquisa da tipicidade pelo juiz. Já a expressão "**ato ímprobo**" será uma fonte de interpretações arbitrárias e conflitantes, como se daria se o estelionato fosse definido como "ato desonesto" ou "ato fraudulento".

Por violar o princípio da reserva legal enquanto exigência de explicitude e clareza na descrição das condutas típicas (função de taxatividade), a criminalização da imputação falsa de "**ato ímprobo**" é visivelmente inconstitucional além de ser inútil, pois já existente em nossa legislação sem tal vício (art. 19 da lei 8.429/92).

Na Constituição Federal de 1988, o princípio da legalidade penal está positivado no artigo 5º, XXXIX, cuja violação ora se suscita. Apenas por meio da edição de leis, a atuação estatal se torna razoavelmente previsível[16], e os indivíduos podem projetar responsavelmente seus planos de ação. A legalidade provê segurança aos jurisdicionados e fomenta a imparcialidade dos órgãos judiciários. Como esclarece Palazzo, o princípio da legalidade *"funciona como garantia diante do poder punitivo-judiciário, incumbido de assegurar a específica* eticidade do direito*, constituída da certeza* jurídica*, e de operar, qual pressuposto objetivo de cognoscibilidade da norma, uma 'valorização' e 'responsabilização' do homem, de sua estrutura espiritualista, e, assim, contribuir para uma efetiva compreensão do* Rechtsstaat*, não mais em termos de rigorosa delimitação do poder punitivo no tocante ao indivíduo, porém de reconhecimento, no homem, de uma capacidade que lhe é própria, inerente, e de uma responsabilidade de autodeterminar-se em face da vontade estatal".*[17]

---

[15] Zaffaroni, E. R., - Batista, N. - Alagia, A. - Slokar, A., Direito Penal Brasileiro, Rio, 2010, ed. Revan, v. II, t. II, p. 171.
[16] Cf., *i. a.*: MORESO, José Juan. Principio de la legalidad y causas de justificación (sobre el alcance de la taxatividade). *Doxa*, n. 24, 2001. p. 525.
[17] PALAZZO, Francesco C. *Valores constitucionais e direito penal.* Trad. Gérson Pereira dos Santos. Porto Alegre: Sergio Fabris, 1989. p. 50.

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB– Brasília/DF CEP 70070-939
Tel: 61 2193-9818 / 2193-9819 Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

No direito ocidental contemporâneo, o princípio da legalidade só foi relativizado por regimes de cunho totalitário. O caso mais eloquente de abandono do princípio da legalidade é a possibilidade, prevista no direito penal nazista, de punição dos atos que violassem não só as normas legais expressas, mas também o "são sentimento do povo".[18] Com o ocaso dos regimes totalitários da primeira metade do século XX, o princípio da legalidade recobrou sua centralidade. Apenas se a lei define como criminosa determinada conduta pode ter lugar a imposição de sanção penal. A atividade do juiz consiste em verificar se os fatos levados a sua apreciação se identificam com a hipótese de incidência prevista na lei (a chamada facti species). Se é o caso, aplica-se a norma e realiza-se a consequência jurídica também prevista no texto legal - a imposição de uma pena. Em um estado de direito, as decisões judiciais na esfera criminal são "*nunca mais do que um texto exato da lei*"[19], cabendo aos magistrados "*estruturar um silogismo perfeito*".[20]

Essa é a razão pela qual os tipos penais criados pelo legislador devem ser descritos com precisão, reduzindo-se a possibilidade do exercício discricionário da jurisdição. É o que se denomina "taxatividade". Apenas quando a conduta está prevista taxativamente no texto legal, legitima-se a imposição da pena. Por essa razão, leis penais excessivamente vagas, que confiram aos magistrados ampla margem de apreciação, padecem de inconstitucionalidade, violando o artigo 5º, XXXIX, da Constituição Federal.

No direito comparado, há diversos precedentes em que cortes constitucionais declararam a inconstitucionalidade de normas penais incriminadoras por não descreverem com objetividade e precisão aceitáveis as condutas que pretendem proscrever. Foi o que ocorreu, por exemplo, na Sentencia C-575/09, proferida pela Corte Constitucional Colombiana, que, dentre outras razões para pronunciar a inconstitucionalidade do art. 461 do Código Penal, entendeu ser reprovável a insegurança associada ao emprego do verbo "ultrajar", na locução "quem ultrajar publicamente a bandeira, o hino ou o escudo da Colômbia":

> *Como antes se dijo uno de los límites a la libertad de configuración del Legislador en materia penal es el deber de observar la estricta legalidad. En punto a este deber, la Corte há señalado "(i) que la creación de tipos penales*

[18] Confira-se o que dispunha o parágrafo 2º do Código Penal alemão, na redação dada em 1935: "Será punido todo aquele que cometa um fato que a lei declare punível ou que mereça uma pena segundo a ideia básica de uma lei penal ou segundo o são sentimento do povo".
[19] MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de la Brède et de. *De l'esprit des lois.* Paris: Éditions Garnier Frères, 1956.
[20] BECCARIA, Cesare. *Dos delitos e das penas*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 32.

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB– Brasília/DF CEP 70070-939
Tel: 61 2193-9818 / 2193-9819 Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

es una competência exclusiva del legislador (reserva de ley en sentido material) y que (ii) es obligatorio respetar el principio de tipicidad: "nullum crimen, nulla poena, sine lege previa, scripta et certa". De manera que el legislador está obligado no sólo a fijar los tipos penales, sino que éstos tienen que respetar el principio de irretroactividad de las leyes penales (salvo favorabilidad), y definir la conducta punible de manera clara, precisa e inequívoca" (subrayas añadidas)[35].

Ciertamente, tal como se hizo mención anteriormente, la expresión "ultrajar" incluye contenidos semánticos diversos.

En efecto, el Diccionario de la Real Academia define la expresión ultrajar como la conducta dirigida a 1. tr. Ajar o injuriar. 2. tr.

Despreciar o tratar con desvío a alguien. 3. tr. El Salv. Y Ven. violar (tener acceso carnal con alguien en contra de su voluntad). Y como sinónimo de ajar, 1. tr. Maltratar, manosear, arrugar, marchitar. 2. tr. Tratar mal de palabra a alguien para humillarle. 3. tr. Hacer que pierda su lozanía alguien o algo. U. t. c. prnl. 4. tr. Desgastar, deteriorar o deslucir algo por el tiempo o el uso. U. t. c. prnl.

El diccionario del uso corriente de María Moliner lo define como "1.(<con, en>) tr. Ofender gravemente a una persona com palabras o con obras: (Ultrajar con palabras. Ultrajar en su dignidad". 2 Despreciar o humillar a una persona. Por su parte, la página web de wordreference.com trae las siguientes variables semánticas del término: 1) tr. Injuriar gravemente a alguien. 2) Despreciar, 3) ajar, deteriorar, estropear. El diccionario de Sinónimos y Antónimos de Editorial Planeta consigna los siguientes sinónimos del término: insultar, injuriar, insolentar, difamar, vejar, despreciar.

En esa medida la expresión "ultraje" incluye contenidos semánticos diversos. En el catálogo de sinónimos que puede asociarse a la expresión ultraje se incluyen acciones como dañar, estropear, deteriorar, deslucir, ofender, humillar, manosear, arrugar, marchitar, tratar mal, insultar, injuriar, insolentar, difamar, vejar, despreciar. Ciertos comportamientos vinculados con el verbo "ultrajar" suponen la agresión física, el deterioro material del bien objeto de ultraje. Otras acciones suponen la intención de humillar, de vilipendiar el bien ultrajado. En el espectro de acciones marcado por dichos límites, están comprendidas por uma parte ciertas conductas ultrajantes que pueden constituir manifestación legítima del derecho a la libertad de expresión, y por otra parte la pluralidad de contenidos semánticos de la expresión puede dar lugar a juicios subjetivos por el juzgador al momento de apreciar una conducta. Piénsese, por ejemplo, em ciertas manifestaciones artísticas que involucren los símbolos patrios o en la utilización de los símbolos patrios en adornos personales o prendas de vestimenta, si bien en ciertos casos este empleo puede ser considerado una exaltación de los símbolos patrios, en otros puede ser interpretado como una forma de mancillar los valores representados en los mismos. Por lo tanto la conducta tipificada en el artículo 461 del Código Penal dista de cumplir con la exigencia de claridad y precisión exigida por el principio de legalidad en materia penal, razón adicional para declarar su inconstitucionalidad.

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB– Brasília/DF CEP 70070-939
Tel: 61 2193-9818 / 2193-9819 Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

A jurisprudência da Suprema Corte dos EUA contém precedentes com teor semelhante. Em Connally v. General Construction Co. (1926), entendeu que a lei vaga seria inconstitucional quando pessoas *"of common intelligence must necessarily guess at its meaning."* Em Kolender v. Lawson (1983), a Corte estabeleceu que *"the void-for-vagueness doctrine requires that a penal statute define the criminal offense with suficiente definiteness that ordinary people can understand what conduct is prohibited and in a manner that does not encourage arbitrary and discriminatory treatment*." Em *Smith v. Goguen* (1974), a Corte enfatizou que "*perhaps the most meaningful aspect of the vagueness doctrine is not actual notice but the other principal element of the doctrine — the requirement that a legislature establish minimal guidelines to govern law enforcement."* Neste último caso, como no precedente colombiano, a Corte também se debruçou sobre norma que criminalizava o uso considerado inadequado de símbolo nacional (bandeira):

> *"The challenged statutory language, which had received no narrowing state court interpretation, is void for vagueness under the Due Process Clause of the Fourteenth Amendment, since, by failing to draw reasonably clear lines between the kinds of nonceremonial treatment of the flag that are criminal and those that are not, it does not provide adequate warning of forbidden conduct, and sets forth a standard so indefinite that police, court, and jury are free to react to nothing more than their own preferences for treatment of the flag.*"

Na hipótese ora submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal, a Lei nº 14.110, de 18 de dezembro de 2020, promove a substituição de uma fórmula dotada de objetividade, passível de ser normativamente circunscrita, por uma fórmula aberta, que confere ao juiz criminal amplo espaço de avaliação subjetiva. Na Lei de Improbidade (art. 19), a denunciação caluniosa apenas se daria quando houvesse a atribuição a outrem de condutas descritas como ímprobas naquele mesmo texto legal. A nova redação do art. 339 do Código Penal, ora impugnada, substitui essa fórmula, que, além de mais precisa, já havia sido testada pelo tempo, por fórmula aberta, desprovida de densidade normativa compatível com o princípio da legalidade.

Não se desconhece ser inevitável que a legislação criminal adote conceitos cuja interpretação comporte algum grau de valoração subjetiva. Porém, se o legislador já dispõe de uma redação legal mais clara e precisa, o emprego da redação mais vaga e indeterminada não se justifica, por ser ostensivamente desnecessária, do que resulta indubitavelmente a violação dos princípios da legalidade e da proporcionalidade. É o critério prescrito pela doutrina. Sousa Filho esclarece o ponto:

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB– Brasília/DF CEP 70070-939
Tel: 61 2193-9818 / 2193-9819 Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

> *"Mesmo se entendida como princípio, a taxatividade não perde sua capacidade de controlar a excessiva imprecisão da lei penal. Uma particular forma de aplicação do juízo de necessidade pode ser útil na averiguação da proporcionalidade da lei penal que restrinja o princípio da taxatividade. Sob essa perspectiva, é necessário saber se existem outras alternativas de descrição típica que realizem o mesmo grau de tutela do bem jurídico com menor ônus para a liberdade. Se houver essa alternativa, o preceito primário da lei penal poderá ser declarado inconstitucional em razão da desnecessária – e, portanto, excessiva – restrição ao princípio da taxatividade*."[21]

No presente caso, o critério é totalmente aplicável. No que toca à hipótese de denunciação de conduta ímproba, já há norma incriminadora, constante do artigo 19 da lei 8.429/92, dotada de objetividade, não se justificando a adoção de conceito perigosamente aberto.

III. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

Na contramão de uma tradição multimilenar, que sempre caracterizou a *denunciação caluniosa* – honrando-lhe o sobrenome – como a conscientemente falsa imputação de um **crime**, a nova lei atribui as mesmas consequências punitivas, a mesma escala penal também à imputação de **infração ético-disciplinar** e à imputação de **ato ímprobo**.

É incontestável que o injusto penal, o crime, constitui o mais grave ilícito de todo o ordenamento jurídico, razão pela qual se lhe destina a mais grave das sanções, a pena. No campo penal, o crime se destaca – por sobre as contravenções e as infrações penais de menor potencial ofensivo criadas pela Constituição da República – como injusto mais grave, e uma prova disso – entre as tantas disponíveis – está na própria disciplina da denunciação caluniosa, cuja pena é reduzida da metade se o agente da denunciação caluniosa imputar à vítima apenas uma contravenção (art. 339, § 2º CP).

Parece evidente que **crime**, **infração ético-disciplinar** e **ato ímprobo** (tomando tal expressão vaga e polissêmica como sinônima de ato de improbidade administrativa) configuram injustos axiologicamente muito distintos, que jamais poderiam produzir efeitos penais idênticos. Alguém objetará, sem razão, que há infrações ético-disciplinares e atos de improbidade administrativa muito graves. Sim, o advogado que não devolve, extinto o mandato,

[21] Sousa Filho, A. B. *O controle de constitucionalidade de leis penais no Brasil*. Belo Horizonte: Forum, 2019. p.368. No Brasil, o critério é sustentado também Porciúncula (Petição inicial, ADI n. 5749). Este último se refere à doutrina de Jakobs, Schönke/Shoröder e Mantovani.

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB– Brasília/DF CEP 70070-939
Tel: 61 2193-9818 / 2193-9819 Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

valores recebidos ao cliente (art. 12, Código de Ética e Disciplina OAB) ou o servidor público que dolosamente causar lesão ao erário ensejando por desvio perda patrimonial (art. 10 da lei 8.429/92) protagonizam injustos relevantes.

O que ocorre é que tais injustos já estão também criminalizados: o advogado responderá por apropriação indébita qualificada (art. 168, § 1º, inc. III CP) e o servidor público responderá por peculato (art. 312 CP). Basta correr os olhos na lei 8.429/92 para perceber que inúmeros crimes contra a Administração Pública também constituem atos de improbidade administrativa: por exemplo, a prevaricação (art. 319 CP) é replicada pelo art. 11, inc. II; a dispensa irregular de licitação (art. 89 da lei 8.666/93) está replicada pelo art. 10, inc. VIII; e assim por diante.

A imputação de tais fatos, realizada com conhecimento da inocência do denunciado, configura denunciação caluniosa por tratar-se de imputação de **crime**. Todos os injustos deontológicos e funcionais mais graves estão criminalizados, e se não o estão é que o legislador entendeu desnecessário ou excessivo criminalizá-los. Ao lado desses, há uma farândula de infrações leves cuja imputação não pode absolutamente ser equiparada à imputação de um crime.

O cliente insatisfeito que representa contra o advogado alegando que ele não se "empenhou permanentemente no aperfeiçoamento pessoal e profissional" (art. 2º, par. ún., inc. IV, Código de Ética e Disciplina OAB) concorre à mesma pena que mereceria se falsamente lhe atribuísse um homicídio: a inépcia profissional e o assassinato conduzem assim ao mesmo desfecho! As infelizes "inovações" da lei nos levarão a outro absurdo: o autor de denunciação de **infração ético-disciplinar** receberá **o dobro da pena** do autor de denunciação de **contravenção penal** (art. 339, § 2º CP).

Viola claramente o princípio da proporcionalidade a estranha equiparação promovida pela nova lei entre crime, infração ético-disciplinar e – seja isto lá o que for – ato ímprobo enquanto conteúdo da imputação conscientemente falsa. Para alcançar uma formulação esquemática, convém recordar que todas as infrações ético-disciplinares e todos os atos de improbidade administrativa mais graves já estão criminalizados, e, portanto, sua imputação a um terceiro sabidamente inocente exprimiria denunciação caluniosa, precisamente porque tais fatos configuram também crimes. Registrada a *inutilidade* da nova lei, podemos assinalar a violação do princípio da proporcionalidade em duas etapas.

Na primeira, a sideral distância axiológica entre um crime e a mera infração ético-disciplinar ordinária por si só revela tal violação pela cominação da **mesma pena** à conduta de imputar falsamente um ou outro injusto. A pena proposta em 1940 por Nelson

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB– Brasília/DF CEP 70070-939
Tel: 61 2193-9818 / 2193-9819 Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

Hungria e seus companheiros da Comissão Revisora, conciliando propostas do projeto de Alcântara Machado[22], foi de reclusão por 2 a 8 anos e multa. Tal pena foi dirigida ao injusto da denunciação caluniosa: ao sujeito que, conhecendo a inocência de alguém, imputa-lhe falsamente um **crime** e obtém a instauração de uma investigação a respeito. Há certo consenso em que o Estado (titular do bem jurídico *administração da Justiça*) e o caluniado (titular dos bens jurídicos *honra* e *liberdade pessoal*) são os sujeitos passivos do crime.

Na jurisprudência estrangeira, encontram-se importantes precedentes reprovando a edição de normas legais que fixam penas iguais para condutas dotadas de gravidade diferente. Nesses casos, entende-se que tem lugar a violação do princípio da proporcionalidade. Foi o que ocorreu na Sentencia C-364/96, da lavra da Corte Constitucional Colombiana:

> "*De la confrontación realizada entre la contravención y el delito infiere la Corte que no sólo se estableció la misma pena, sino que se asignó a la contravención un tratamiento más gravoso que a aquél, lo cual resulta desproporcionado e irrazonable. Si el legislador consideraba que la conducta de hurto calificado, cuando el valor de lo apropiado es inferior a diez salarios mínimos legales mensuales, es un hecho de menor transcendência sociojurídica, y lo calificó como contravención, debió ser consecuente con su valoración y, por tanto, debió otorgarle um trato punitivo menos gravoso que el fijado para el delito.*"

No mesmo sentido, a Corte Constitucional Italiana considerou inconstitucional norma que cominava à conduta de não portar os documentos que veiculavam autorização para a caça a mesma pena prevista para a conduta, mais grave, de quem caçava sem possuir a autorização. Obviamente, não portar a autorização é menos grave que não possuí-la. Confira-se o teor do precedente (Sentenza n. 218 del 1974):

> *Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha deciso che rientra nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura della pena e che, quando siffatto potere sia contenuto nei limiti della razionalità, non vi é violazione dell'art. 3 della Costituzione.*
> *La disparità di trattamento denunziata con l'ordinanza di rinvio palesemente eccede da tali limiti, mancando ogni elemento logico che possa spiegare il*

[22] Em seu projeto, o acadêmico paulista propunha reclusão de 1 a 5 anos e multa, porém se resultasse condenação do inocente superior a 5 anos a reclusão seria de 1 a 15 anos e multa (art. 179 e § 1º). A milenar tradição talional deste delito ainda subsitia em nosso CP de 1890, que cominara à denunciação caluniosa a mesma pena do crime imputado (art. 264) e inspirou a proposta de Alcântara Machado.

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB– Brasília/DF CEP 70070-939
Tel: 61 2193-9818 / 2193-9819 Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

> *fondamento giuridico e razionale di una normativa come quella dell'art. 8 impugnato, il quale punisce - con la revoca della licenza di caccia da tre a cinque anni, nonché con le pene prevedute (dal precedente art. 7) a carico di chi cacci senza licenza - in modo identico chi non sia assicurato e chi, pur essendo assicurato, non sia stato in grado di darne la prova all'agente che gliene abbia fatto richiesta.*
> *(...)*
> *Ne consegue che la norma denunziata, nei limiti risultanti dalle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata illegittima, restando nella discrezionalità del legislatore - con il limite di una ragionevole differenziazione rispetto alla fatti specie di chi caccia senza essere assicurato - lo stabilire con quale sanzione debba essere punito chi, pur essendo assicurato, é sorpreso a cacciare privo dei documenti dimostrativi.*
> *Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, penultimo comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. l016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, limitatamente alla parte in cui si riferisce al soggetto che, pur avendo l'assicurazione, é sorpreso a cacciare privo dei soli documenti dimostrativi.*

Numa segunda etapa, que poderia antecipar-se à primeira sem maiores desarranjos, cabe a pergunta: é *necessário* criminalizar a imputação falsa de uma infração ético-disciplinar leve ou mediana? (Sim, as graves estão já criminalizadas e sua imputação é na realidade a imputação de crime.) Não se estará aí transgredindo a proibição de excesso (*Übermassverbot*)? E não se estará simultaneamente criando empecilhos ameaçadores ao exercício do direito de petição? Reclamar da negligência ou do erro técnico de engenheiros, médicos e advogados, ou representar contra a incúria ou improbidade do servidor público se converte agora em atividade de risco![23]

A questão da proporcionalidade em abstrato, ou seja, aquela exigência de que "a sanção prevista pelo legislador guarde relação com a gravidade da conduta tipificada como delito"[24] foi abordada pelo penalismo ilustrado[25], porém só seria aprofundada teoricamente na

[23] Contemplado expressamente na Carta (art. 5º, inc. XXXIV, al. *a*), o direito de petição respalda "uma queixa, uma reclamação" (Silva, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional Positivo, S. Paulo, 2005, ed. Malheiros, p. 443). A "qualquer pedido ou reclamação", de cunho revisivo ou disciplinar, se refere o Min. Gilmar Mendes (em Ferreira Mendes, Gilmar – Mártires Coelho, Inocêncio – Gonet Branco, Paulo Gustavo, Curso de Direito Constitucional, S. Paulo, 2008, ed. Saraiva, p. 566). A dimensão política do direito de petição, que "assegura aos cidadãos a possibilidade de interferir e auxiliar na tomada de decisões" através de sua queixa foi ressaltada por Adriana da Costa Ricardo Schier (A Participação Popular na Administração Pública: o Direito de Reclamação, Rio, 2001, ed. Renovar, p. 73).

[24] Assim Lopera Mesa, Gloria Patricia, *Principio de Proporcionalidad y Ley Penal,* Madri, 2006, ed. C. Est. Pol. y Constitucionales, p. 175. No mesmo sentido Aguado Correa, T., *El Principio de Proporcionalidad en Derecho Penal*, Madri, 1999, ed. Edersa, p. 278.

[25] Em 1748 Montesquieu intitulou o capítulo XVI do livro VI da obra que o imortalizaria da seguinte forma: "Da

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB– Brasília/DF CEP 70070-939
Tel: 61 2193-9818 / 2193-9819 Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

segunda metade do século XX pela jurisprudência dos tribunais constitucionais europeus e pelo corpo doutrinário que se costuma designar por neoconstitucionalismo.

Apesar de não figurar explicitamente em nossa declaração de garantias fundamentais (art. 5º CR), o que aliás não ocorreu apenas conosco[26], o princípio da proporcionalidade imprime suas marcas em inúmeras passagens da Constituição, assinaladas minuciosamente por Mariângela Gama de Magalhães Gomes[27], e já foi proclamado inúmeras vezes por nossa Corte Suprema[28]. Transcreva-se trecho de recente aresto que parece dirigido à estranha criminalização das reclamações ético-disciplinares, da lavra do eminente Min. Alexandre de Moraes:

> "Reputa-se violando o princípio da proporcionalidade quando não se observar a necessidade concreta da norma para tutelar o bem jurídico a que se destina"[29].

Falta idoneidade (ou adequação) para a grave pena (2 a 8 anos de reclusão) que passa a assombrar os insatisfeitos com serviços profissionais, e o resultado é que a lei produzirá mais danos do que qualquer benefício que idealisticamente se pudesse esperar de tal criminalização. Como disse com exatidão Mir Puig, "cabe exigir que o interesse que se espera proteger seja proporcional à gravidade da intervenção penal, de modo que esta não seja mais grave do que o mal que pretenderia evitar"[30].

A criminalização da conduta de denunciar faltas disciplinares, ainda que menos graves, produzirá o que a jurisprudência norte americana denomina "chilling effect" (efeito resfriador). Os usuários dos serviços ficarão intimidados de exercer seu direito de denunciar faltas éticas praticadas pelos profissionais diante da possibilidade da criminalização. O sistema de fiscalização das profissões reguladas, por seu turno, não receberá devidamente as

---

justa proporção das penas com o crime" (O Espírito das Leis, trad. F. H. Cardoso e L. Martins Rodrigues, S. Paulo, 1962, ed. Difel, v. 1º, p. 115); em 1764, Beccaria preconizava: "As penas devem ser proporcionadas entre si e aos crimes" (Dos Delitos e das Penas, § XIX, in fine); em 1780 Filangieri afirmava que "a justiça, a razão e o interesse público reclamam igualmente esta desejada proporção entre os delitos e a pena" (Ciencia de la Legislación, trad. J. Ribera, Madri, 2018, ed. Bol. Of. Estado, v. I, p. 1024).

[26] "*La mayoría de la doctrina penal se muestra de acuerdo en reconocer rango constitucional al principio de proporcionalidad, a pesar de la ausencia de mención expresa en el Texto de 1978"* (Mata Barranco, Norberto J. de la, *El Principio de Proporcionalidad Penal*, Valência, 2007, ed. T. lo Blanch, p. 69).

[27] O Princípio da Proporcionalidade no Direito Penal, S. Paulo, 2003, ed. RT, p. 62, nota 77.

[28] Por exemplo, na ADI nº 4424/DF, rel. Min. Marco Aurélio.

[29] ADI nº 4911/DF, j. 23.nov.20, p. 3.dez.20.

[30] Mir Puig, Santiago, em Carbonell Mateo, J.C. *et alii* (orgs.), *Constitución, Derechos Fundamentales y Sistema Penal*, Valência, 2009, ed. T. lo Blanch, t. II, p. 1364.

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB– Brasília/DF CEP 70070-939
Tel: 61 2193-9818 / 2193-9819 Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

reclamações dos ofendidos, do que resultará, eventualmente, a preservação, no sistema, de profissionais desprovidos de compromisso ético.

Na jurisprudência norte-americana recente, encontra-se precedente (McDonnell v. United States, 2016) relativo a governador que recebera empréstimos e presentes de empresa privada. Mas a Corte entendeu que a adoção de interpretação ampla do conceito de "ato de ofício" (*official act*) poderia desencorajar a interação natural entre governantes e seus representados, produzindo resultado incompatível com um dos valores mais caros à democracia. A confirmação da condenação do governador colocaria sob suspensão a atuação dos políticos em geral, que, ordinariamente, interagem com os representantes de empresas:

> *In addition to being inconsistent with both text and precedent, the Government's expansive interpretation of "official act" would raise significant constitutional concerns. Section 201 prohibits quid pro quo corruption—the exchange of a thing of value for an "official act." In the Government's view, nearly anything a public official accepts—from a campaign contribution to lunch—counts as a quid; and nearly anything a public official does—from arranging a meeting to inviting a guest to an event— counts as a quo. (...)*
> *But conscientious public officials arrange meetings for constituents, contact other officials on their behalf, and include them in events all the time. The basic compact underlying representative government assumes that public officials will hear from their constituents and act appropriately on their concerns (...).*
> *The Government's position could cast a pall of potential prosecution over these relationships if the union had given a campaign contribution in the past or the homeowners invited the official to join them on their annual outing to the ballgame. Officials might wonder whether they could respond to even the most commonplace requests for assistance, and citizens with legitimate concerns might shrink from participating in democratic discourse.*
> *This concern is substantial. White House counsel who worked in every administration from that of President Reagan to President Obama warn that the Government's "**breathtaking expansion of public-corruption law would likely chill federal officials' interactions with the people they serve and thus damage their ability effectively to perform their duties" (...)***
> *A related concern is that, under the Government's interpretation, the term "official act" is not defined "with sufficient definiteness that ordinary people can understand what conduct is prohibited," or "in a manner that does not encourage arbitrary and discriminatory enforcement." (...) Here, where a more limited interpretation of "official act" is supported by both text and precedent, we decline to "construe the statute in a manner that leaves its outer boundaries ambiguous and involves the Federal Government in setting standards" of "good government for local and state officials." (...)"*

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB– Brasília/DF CEP 70070-939
Tel: 61 2193-9818 / 2193-9819 Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

Especialmente relevante é o precedente da lavra do Tribunal Constitucional Espanhol (Sentencia 136/1999) que considerou inconstitucional preceito que criminalizava a colaboração com grupo armado por entender que o tipo era excessivamente aberto, o que, na hipótese, podia dar lugar à restrição da atividade política legítima e do exercício da liberdade de expressão:

> *Nuestra decisión ha de ser diferente en relación con el juicio estricto de proporcionalidad, que es el que compara la gravedad del delito que se trata de impedir -y, en general, los efectos benéficos que genera la norma desde la perspectiva de los valores constitucionales- y la gravedad de la pena que se impone -y, en general, los efectos negativos que genera la norma desde la perspectiva de los valores constitucionales-. La norma que se ha aplicado a los recurrentes no guarda, por su severidad en sí y por el efecto que la misma comporta para el ejercicio de las libertades de expresión y de información, una razonable relación con el desvalor que entrañan las conductas sancionadas.*
> *Ese desequilibrio resulta manifiesto si se tienen en cuenta las cuatro circunstancias siguientes:*
> *a) En cuanto a las conductas sancionadas no cabe duda de que son potencialmente peligrosas en la medida en que son constitutivas de colaboración con banda armada, pero resultaron en la realidad muy alejadas de los peligros que la norma aplicada quiere finalmente evitar. Recuérdese, en primer lugar, que no estamos ante una conducta directamente constitutiva de un resultado de colaboración con banda armada, como lo hubiera sido por ejemplo la difusión efectiva de la intimidación contenida en los mensajes televisivos y radiofónicos a que se ha hecho referencia, sino ante un acto de colaboración -tal como lo calificó la Sala sentenciadora- tendente a tal resultado de efectiva colaboración. (...)*
> *b) Por el contrario, en el otro plato de la balanza, en el de los costes fácticos que la medida comporta para los valores constitucionales, debe destacarse, en primer lugar, la muy significativa entidad de la pena: una privación de libertad de una duración mínima de seis años y un día y máxima de doce y una multa de cuantía comprendida entre 500.000 y 2.500.000 pesetas. Esta misma pena de prisión mayor, se asignaba en el Código Penal de 1973, por ejemplo, a los integrantes de bandas armadas (art. 174.3), a los ejecutores de una sedición (art. 219.3º), al aborto doloso no consentido por la embarazada (art. 411, párrafo 1º.1), a las mutilaciones de miembro no principal (art. 419), a las agresiones sexuales graves (art. 430), al robo con torturas (art. 501.4º) o al incendio de masas forestales con peligro para la vida de las personas [art. 553 bis a)].*
> *En el mismo sentido se constata que la pena de prisión prevista para las conductas de colaboración con o favorecimiento de bandas armadas en la legislación penal de los países de nuestro entorno jurídico y socio- cultural es, de uno o seis meses a cinco años en Alemania -§§ 129 y 129 a) del Código Penal alemán-, de un día a tres años en Austria - § 279 del Código Penal austríaco-, de hasta cinco años en el Reino Unido -arts. 10 y 11 de la Ley de Prevención del Terrorismo-, de quince días a cuatro años en Italia - arts. 307,*

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB– Brasília/DF CEP 70070-939
Tel: 61 2193-9818 / 2193-9819 Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

> *378 del Código Penal italiano-.*
> *c) En la relativización de la gravedad de los comportamientos sancionados y en los costes sociales de la norma penal incide el hecho de que la misma se aplica a la expresión de ideas e informaciones por parte de los dirigentes de una asociación política legal en el seno de una campaña electoral y dirigida a la petición del voto de los ciudadanos. Hemos reiterado que la difusión de estas ideas e informaciones y este modo de participación en la actividad política no constituye un ejercicio lícito de las libertades de expresión, de información y de participación política y, por ello, no están tuteladas por esos derechos constitucionales y por ello pueden ser objeto de sanción penal; sin embargo, también hemos señalado que es indudable que* ***las conductas incriminadas son actividades de expresión de ideas e informaciones y constituyen una forma de participación política y, en consecuencia, una sanción penal desproporcionada puede producir efectos de desaliento respecto del ejercicio lícito de esos derechos****. En suma, aun admitiendo la legitimidad del recurso a la vía penal, la pena no puede proyectarse con la dureza que el tipo previene sobre la universalidad de los componentes del órgano dirigente de una asociación política que, si bien extralimitándose, han actuado en un ámbito en el que las formaciones políticas deben operar con la mayor libertad sin más limitaciones que las estrictamente necesarias para preservar la libertad de los ciudadanos. (...)*
> ***La aplicación de un precepto que contempla una pena mínima de seis años y un día produce un claro efecto disuasorio del ejercicio de las libertades de expresión, comunicación y participación en la actividad pública, aunque las conductas sancionadas no constituyan ejercicio legítimo de las mismas.***
> *d) Finalmente debe tenerse en cuenta que ese efecto disuasorio se refuerza en supuestos como el presente en el que la relativa indeterminación del precepto, aunque no plantee problemas desde el punto de vista de la taxatividad, puede crear alguna incertidumbre acerca de si la expresión de unas ideas, la comunicación de una información o la participación en una determinada actividad pública es lícita o, por el contrario, resulta muy severamente penada.* ***Esta incertidumbre puede inhibir de modo natural el ejercicio de tales libertades, necesarias para el funcionamiento democrático de la sociedad y radicalmente imprescindibles cuando tal ejercicio se refiere a los partidos políticos y al momento en el que se dirigen a recabar la voluntad de los ciudadanos.***

Não há a menor dúvida do cabimento do controle de constitucionalidade[31]. No caso presente, a primeira prova da violação do princípio da proporcionalidade está na cominação da mesma sanção penal a injustos axiologicamente muito distintos. Imputar um crime e imputar uma falta deontológica representam injustos que não podem ser equiparados, e que, portanto, hão de merecer penas distintas – se porventura queixar-se de uma falta deontológica duvidosa ou inocorrente merecesse pena. É de clareza solar a inidoneidade ou

[31] Assim Bozza, Fábio da Silva, Bem Jurídico e Proibição de Excesso como Limites à Expansão Penal, S. Paulo, 2015, ed. Almedina, p. 243. No mesmo sentido, Magalhães Gomes, Mariângela Gama de, op. cit., p. 81.

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB– Brasília/DF CEP 70070-939
Tel: 61 2193-9818 / 2193-9819 Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

inadequação daquela grave pena (2 a 8 anos de reclusão) para os reclamantes dos Conselhos profissionais ou das repartições públicas; seu direito de petição estará, queiram ou não, embaraçado. Trata-se de um excesso que o Estado de direito não pode consentir.

IV. PRESERVAR AS OPÇÕES LEGISLATIVAS NÃO INCONSTITUCIONAIS

O movimento geral da nova lei foi no sentido de exigir como momento consumativo da denunciação caluniosa a instauração de procedimentos mais formalizados. Ao invés de mera **investigação policial**, exige-se agora **inquérito policial**; ao invés de **investigação administrativa**, exige-se agora **processo administrativo disciplinar**. As demais modalidades de resultado (instauração de **processo judicial**, de **inquérito criminal** e de **ação de improbidade administrativa**) reproduzem a redação anterior, e cabe elogiar a previsão nova do resultado de instauração de **procedimento investigatório criminal**, aquela investigação conduzida pelo Ministério Público[32] que escapara ao tipo legal: andou bem o legislador em colmatar tal lacuna.

Ainda que o fundamento justificativo de "ajustar o tipo penal da denunciação caluniosa à *mens legis* da nova Lei de Abuso de Autoridade" seja por completo impertinente[33], não há inconstitucionalidade nas opções perfilhadas. Um velho debate doutrinário[34] e jurisprudencial[35] ficará assim resolvido. Doravante, a representação conscientemente falsa protocolada contra inocente na Delegacia de Polícia da qual não resultar instauração de **inquérito policial** (arts. 4º ss CPP) configurará tão somente tentativa do crime.

A presente ação não busca despenalizar a denunciação caluniosa, que deve seguir sendo considerada uma conduta criminosa grave, mas tem por objetivo corrigir o excesso legislativo que amplia a sua incidência para hipóteses normativas abertas e de interpretação

[32] Regulada pela Resolução CNMP nº 181, de 7.ago.17, alterada pela Resolução CNMP nº 183, de 24.jan.18.
[33] A inspiração seria o parágrafo único do artigo 27 da lei nº 13.869, de 5.set.19. Contudo, na disciplina do delito do Promotor de Justiça que requisita ou do Delegado de Polícia que instaura "procedimento investigatório de infração penal ou administrativa" sem dispor de qualquer indício que sustente a iniciativa impunha-se ressalvar precisamente a sindicância prévia (a VPI) graças à qual se tentasse identificar algum indício. Sem a ressalva, estariam atadas as mãos do MP e da polícia para checar informes. Nada disso tem a ver com a denunciação caluniosa.
[34] Alguns autores sustentaram minoritariamente que para a consumação do crime "não basta a simples instauração de sindicância policial, sendo necessária (...) a abertura de inquérito" (Fragoso, Heleno, Lições de Direito Penal – P.E., Rio, 1988, ed. Forense, v. II, p. 523); "e não mera sindicância formal" (Mayrink da Costa, Álvaro, Direito Penal, Rio, 2011, ed. Forense, v. 7, p. 329).
[35] Em 1979, a Segunda Turma do STF, no RHC 56.856/ES, relator o Min. Cordeiro Guerra, circunscrevia a consumação do crime à instauração de inquérito policial, recusando bastasse a sindicância preliminar. Prevalece hoje no STJ o entendimento de que seria "prescindível a formalização de inquérito policial ou de termo circunstanciado" (AgRg no AREsp nº 1.222.635/ES, rel. Min. Nefi Cordeiro).

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB– Brasília/DF CEP 70070-939
Tel: 61 2193-9818 / 2193-9819 Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

subjetiva, de modo a restabelecer os parâmetros de certeza, objetividade e proporcionalidade que legitimam a aplicação do direito penal no Estado Democrático de Direito.

V. DA MEDIDA LIMINAR

Em razão da relevância temática e da urgência do feito, este Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil requer seja concedida medida cautelar, uma vez que estão preenchidos os pressupostos autorizadores constantes nos arts. 10 e 11, da Lei 9.868/1999. O *fumus boni iuris* está presente no feito, uma vez que ficou demonstrada a violação aos princípios constitucionais da legalidade e da proporcionalidade, decorrente da incorporação, ao tipo penal de denunciação caluniosa, de expressões que padecem de imprecisão normativa e de abertura conceitual, como é o caso de "infração ético- disciplinar" e "ato ímprobo".

Por sua vez, o *periculum in mora* também está presente no caso em comento, tendo em vista que a vagueza semântica dessas expressões compromete a segurança jurídica e amplia de modo desproporcional a criminalização de condutas, uma vez que as expressões "infração ético- disciplinar" e "ato ímprobo" são genéricas, sujeitas a variações interpretativas, o que compromete a previsibilidade do direito penal.

A inquestionável presença de vícios sinaliza mais que simples fumaça de bom direito e os riscos que podem concretizar-se na aplicação da nova lei sugerem a imediata **concessão de medida cautelar suspendendo a vigência da lei 14.110/20**.

Além disso, o § 2º, do art. 11, dispõe que "A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário".

Desse modo, enquanto a nova lei se submete ao filtro de constitucionalidade, a redação anterior do artigo 339 do Código Penal deve ser aplicada, para fornecer segurança jurídica até que a Corte Suprema decida sobre sua forma final.

VI. DOS PEDIDOS

Pelo exposto, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil requer:

a) a notificação da **Câmara dos Deputados** e do **Senado Federal,** por intermédio de seus Presidentes, e do Exmo. Sr. **Presidente da República,** para que, como órgãos/autoridades responsáveis pela elaboração dos dispositivos impugnados, manifestem-se, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a medida cautelar, nos termos do art. 10, da Lei nº 9.868/99;

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB– Brasília/DF CEP 70070-939
Tel: 61 2193-9818 / 2193-9819 Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

b) a **concessão de medida cautelar**, com base no artigo 10 da lei nº 9.868/99, para imediata suspensão da vigência das locuções "*infração ético-disciplinar" e "ato ímprobo"* constantes da redação conferida pela lei nº 14.110, de 18 de dezembro de 2020, ao artigo 339 do Código Penal, com efeitos retroativos ao dia de sua publicação (21.dez.20);

c) a notificação da **Câmara dos Deputados** e do **Senado Federal,** por intermédio de seus Presidentes, e do Exmo. Sr. **Presidente da República,** para que, como órgãos/autoridades responsáveis pela elaboração dos dispositivos impugnados, manifestem-se, querendo, sobre o mérito da presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 6, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99;

d) a notificação do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União, nos termos do artigo 103, §§ 1º e 3º, da Constituição da República; e

e) ao final, a **procedência do pedido de mérito**, para que seja declarada a inconstitucionalidade das locuções "infração ético-disciplinar" e "ato ímprobo" constantes da redação conferida pela lei nº 14.110, de 18 de dezembro de 2020, ao artigo 339 do Código Penal.

Termos em que, aguarda deferimento.
Brasília/DF, 18 de setembro de 2025.

José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral
Presidente do Conselho Federal da OAB
OAB/AM 3.725
OAB/DF 45.240

Marcus Vinicius Furtado Coêlho
Presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais
OAB/DF 18.958

Bruna Santos Costa

Bruna Santos Costa
OAB/DF 44.884

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNA SANTOS COSTA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro